

1500535-63.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado MARCO AURÉLIO FABIANO foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha DAVISON DANIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1424,

Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1500535-63.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

1500535-63.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO AURÉLIO FABIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra MARCO AURÉLIO FABIANO vulgo "Paquito", pela suposta prática do crime do artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso III e artigo 34, todos da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 16, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Na denúncia, narra-se que:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela Promotora de Justiça infra-assinada, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no incluso auto de prisão em flagrante, oferecer DENÚNCIA em face de MARCO AURÉLIO FABIANO, vulgo "Paquito", qualificado às fls. 08/09, pelo fato punível que passa a relatar.

Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 06 de junho de 2022, por volta 16h10, no Terminal Rodoviário, situado na Rua José de Silveira Mendes e na Rua Redenção da Serra, nº 335, Jardim Trabalhista nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, MARCO AURÉLIO FABIANO, vulgo "Paquito", trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso líquido

de 35,69 gramas, 06 (seis) eppendorfs contendo cocaína pulverizada, com peso líquido de 2,9 gramas e 16 (dezesseis) eppendorfs da mesma substância, com peso líquido de 6,5 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/20 e laudo de constatação de fls. 19/20.

Consta, ainda, que no mesmo horário supramencionado, no Terminal Rodoviário, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, MARCO AURÉLIO FABIANO, vulgo "Paquito", portava 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, de uso permitido, com numeração suprimida, bem como 07 (sete) cartuchos íntegros do mesmo calibre, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/20.

Consta, por fim, que logo após às 16h10, na Rua Redenção da Serra, nº 335, Jardim Trabalhista, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, MARCO AURÉLIO FABIANO, vulgo "Paquito", guardava objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que na data sobredita, policiais militares em patrulhamento pelo Terminal Rodoviário de Cachoeira Paulista divisaram MARCO AURÉLIO nas plataformas de embarque/desembarque com uma mochila nas costas.

Ao perceber a aproximação policial, MARCO AURÉLIO dispensou a mochila e empreendeu fuga. Os policiais, então, recolheram a mochila dispensada e saíram em perseguição ao denunciado, que foi abordado nas proximidades da Rua Ovídio Alves Capucho.

Durante a abordagem, foi localizado com MARCO AURÉLIO um aparelho celular e uma corrente de metal. Ao ser indagado, o indigitado mencionou que estava indo para a cidade de Carapicuíba porque tomou conhecimento de um mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Na mochila dispensada por MARCO AURÉLIO foi localizado um revólver, calibre 38, com numeração suprimida, 07 (sete) cartuchos íntegros do mesmo calibre, bem como 01 (uma) porção de maconha, 06 (seis) eppendorfs contendo cocaína e R\$ 32,00 (trinta e dois reais).

O denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia. No local, a DD. Autoridade Policial informou a existência de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor MARCO AURÉLIO, então, determinou seu cumprimento.

Os policiais dirigiram-se até a casa do denunciado, situada na Rua Redenção da Serra, nº 335, Jardim Trabalhista. No local foram localizados 16 (dezesseis) eppendorfs contendo cocaína, 73 (setenta e três) pinos vazios, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) pote de pó royal, bem como dinheiro.

A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro.[...]

Às fls. 162/163, houve o recebimento da denúncia.

Às fls. 224/228, o réu ofereceu resposta à acusação.

Às fls. 249/251, negou-se a absolvição sumária do Réu e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em 21/10/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação penal deve ser julgada procedente; há prova da materialidade e da autoria; há prova do tráfico de drogas; também há provas do crime do art. 34, bem como do crime do art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003;

Em alegações finais, a defesa afirmou que: deve haver a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; não há provas de que as drogas encontradas na residência sejam do Réu; o Réu deve ser absolvido quanto ao crime do art. 34; o Réu confessou o crime do art. 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003; a pena deve ser fixada no mínimo legal, com substituição por restritivas de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e manter em depósito.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, os autos de exibição e apreensão de fls. 22/23 e 24/25. demonstram que foram apreendidas: a) na posse do Réu, 6 pinos de cocaína e 1 porção de maconha; b) no endereço objeto da busca e apreensão, 16 pinos de cocaína.

Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 28/30, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 320/322 constatou que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Trata-se precisamente do total de 35,69g de massa líquida de maconha e 8,59g de massa líquida de cocaína.

A imputação também é confirmada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/19), pelo autos de exibição e apreensão (fls. 22/25) e pelas imagens de fls. 41/49, 51 e 53.

Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado MARCO AURÉLIO FABIANO foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha DAVISON DANIEL BATISTA afirmou que: estava em patrulhamento pelo Terminal Rodoviário; quando entraram na rodoviária, perto da plataforma de passageiros, o Réu jogou uma sacola no chão e saiu correndo, ao ver a viatura; pegaram a mochila; o parceiro conseguiu correr atrás dele e abordá-lo; na posse do Réu, só havia um celular; na mochila, havia um revólver calibre .38, drogas e dinheiro; em entrevista com o Réu, ele falou que iria para Carapicuíba fugir do cumprimento de um mandado de prisão e que a arma era para proteção dele, em razão de desafetos que tinha na região; o Réu falou que tinha comprado a arma em Lorena; na delegacia, tomaram conhecimento de um mandado de busca domiciliar; foram até a casa dele para apoiar os policiais civis; no local, encontraram mais drogas e dinheiro, bem como balança de precisão, que ele reconheceu como dele; na mochila, encontraram maconha e cocaína.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha MAURÍCIO DA CONCEIÇÃO SILVA afirmou que: estavam em patrulha próximos ao Terminal Rodoviário; viram o Réu; quando o Réu viu a viatura, jogou a mochila no chão e fugiu; recuperaram a mochila e foram atrás do Réu; o Réu foi abordado e com ele nada de ilícito foi encontrado; na mochila, havia um revólver calibre .38, maconha e cocaína; encaminharam para a delegacia de Cachoeira Paulista; na delegacia, souberam de um mandado de prisão contra o Réu e um mandado de busca domiciliar; junto com a equipe da PCSP, foram até a residência e encontraram drogas e outros objetos, que foram apreendidos.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha LUÍS CÉSAR FRANKLIN afirmou que: a PM fazia patrulhamento perto da rodoviária e visualizou o Réu; sabiam que o Réu estava com um mandado de prisão preventiva; o Réu viu os policiais e fugiu, deixando uma mochila para trás; os PM detiveram o Réu e, na mochila, encontraram um revólver calibre .38, maconha e cocaína; os PM conduziram o Réu até a delegacia; a autoridade policial determinou que dessem cumprimento ao mandado de busca na casa

do Réu; foram até o local com a PM; lá, encontraram mais 16 pinos de cocaína, balanças de precisão e pinos vazios; além disso, colheram outros elementos ligados a um furto de que ele é investigado; o Réu estava com uma passagem para Carapicuíba, com intenção de ir para aquela cidade; Em sua oitiva em juízo, a informante HARIADNY DE FREITAS afirmou que: o Réu mora na mesma casa dela (é padrasto); pelo que sabe, o Réu sempre trabalhou; o Réu trabalhou um tempo no caminhão de lixo; é um bom padrasto; quando o Réu foi preso, ele morava com a mãe; o Réu nunca teve envolvimento com tráfico de drogas; Em sua oitiva em juízo, a informante VERA LUCIA FABIANO afirmou que: o Réu é um bom filho; no dia em que os policiais foram, tinha viajado para SP; ligaram informando que o policial tinha entrado na casa delas; o Réu não mora com ela; o Réu mora do lado de fora; os policiais arrebentaram o portão e entraram; só chamaram depois o irmão do Réu; os irmãos não viram o que levaram; levaram a televisão e outros móveis; arrebentaram a porta de casa; não sabe da localização de drogas; sabia que o Réu era usuário de drogas; o Réu morava com a esposa, na Margem Esquerda, n. 29 de março, n. 25; a informante mora na Rua Redenção da Serra, n. 335; Em seu interrogatório, o Réu MARCO AURÉLIO FABIANO afirmou que: com ele, encontraram maconha, cocaína e o revólver calibre .38; estava indo para Carapicuíba; só tinha a droga que estava com ele; a rua Redenção da Serra é o endereço da mãe; a casa da mãe tava vazia; quando entraram na casa, não tinha ninguém; o irmão morava no fundo; estava no local há 2 ou 3 dias; estava fugindo do mandado de prisão, para se apresentar; nega as drogas na rua Redenção da Serra; Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório. Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato. (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria

da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos colhidos foram coerentes entre si, convergindo quanto aos seguintes fatos: a) o Réu foi surpreendido quando tentava fugir; b) em sua mochila, foi achada certa quantidade de maconha e cocaína; c) quando foram cumprir um mandado de busca e apreensão, encontraram mais drogas, como se vê às fls. 24/25 e 48/49, 51 e 53.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria - Pena-base fundamentadamente exasperada - Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

Ressalte-se que, nos autos de n. 1500339-98.2022.8.26.0102, a decisão de fls.

117/122 determinou a busca e apreensão em um endereço ligado ao Réu (Rua Redenção da Serra, n. 355), que coincide, inclusive, com os relatos feitos em disque-denúncia (fls. 59/62 dos presentes autos).

Além disso, some-se a isso o fato de que a informante HARIADNY confirmou que o Réu estava morando no endereço em questão, o que em parte foi afirmado pelo Réu em seu interrogatório (disse que estava lá há 2 ou 3 dias).

Assim, não há dúvidas quanto ao fato de que o Réu estava, de fato, mantendo em depósito a droga apreendida no endereço.

Ao contrário do argumentado pela defesa técnica, não é viável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

O TJSP tem precedentes no sentido de que não deve haver a desclassificação quando as circunstâncias da conduta indicarem que o agente, surpreendido em posse de drogas, não o fazia para uso próprio:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500579-91.2021.8.26.0597; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Parcial razão. Materialidade e autoria indúvidas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, com peso bruto de 4,72g (quatro gramas e setenta e dois centigramas) e 01 (um) tablete de maconha, com peso bruto de 500,06g (quinhentos gramas e seis centigramas). Prova oral robusta. Inviabilidade de desclassificação para o uso próprio. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria comporta reparos. Quantidade de entorpecentes apreendida não ultrapassa a normalidade à espécie, devendo manter-se o aumento da basilar apenas com relação aos maus antecedentes, na fração de 1/6 (um sexto). Comprovada reincidência. Impossível a concessão do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500181-14.2021.8.26.0123; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da defesa - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Conduta criminosa verificada a partir das circunstâncias da prisão em flagrante - Suposto usuário de drogas admitiu na fase inquérito que o acusado lhe vendeu parte da droga apreendida - Desclassificação para o artigo 28 da Lei Drogas - Impossibilidade - Contexto fático não sugere que a droga seria para o consumo do acusado, mesmo porque 4 porções de cocaína foram apreendidas na posse de terceiro, após o acusado tê-las vendido - Presentes os requisitos do "privilégio" (§ 4º do artigo 33 da Lei de Drogas), deve a diminuição de pena ser feita na fração máxima (2/3) - Inviabilidade de se operar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como modificar o regime semiaberto, porquanto, no curso desta ação penal, o acusado foi condenado outras duas vezes pelo mesmo crime - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501281-78.2020.8.26.0530; Relator (a): Heitor Donizete

de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022) (grifos acrescidos)

No caso concreto, o fato de manter em depósito, na forma da imagem de fl. 44, indica que a conduta do agente não se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas, de sorte que é inviável a desclassificação pretendida.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu MARCO AURÉLIO FABIANO, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu MARCO AURÉLIO FABIANO pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais na forma da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: não há excepcionalidade que justifique a majoração da pena-base pela natureza ou quantidade da droga.

Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes a reconhecer.

No caso concreto, tendo em vista que o agente confessou a posse da droga, mas

afirmou que ela se destinava a uso pessoal, não é possível aplicar a atenuante da confissão:

Súmula 630 (STJ). A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Desta forma, não aplico a referida atenuante, razão pela qual a pena-intermediária é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à terceira-fase, tendo em vista a condenação pelo crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, deixo de aplicar a causa de aumento pleiteada pelo MP.

Além disso, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que exige a presença de quatro requisitos para a diminuição da pena: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) ausência de dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

Em sede de julgamentos de recursos especiais repetitivos (Tema 1139), o STJ fixou tese no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Desta forma, só é possível afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas se: a) houver maus antecedentes, inclusive por fato anterior à presente imputação, mas com trânsito em julgado posterior ao presente processo; b) houver reincidência; ou c) as circunstâncias do caso concreto (não outros processos) indicarem que não se trata de uma conduta pontual ou iniciante e que há efetiva dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa. No caso concreto, não há prova de nenhuma das hipóteses acima, de sorte que entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com relação à fração de diminuição, já que o dispositivo prevê uma margem de 1/6 a 2/3, a doutrina sugere a utilização dos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas:

"91-C. Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: 'o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente'" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, vol. 1, p. 424) (grifos acrescentados)

Considerando a apreensão de droga da espécie cocaína, a pena intermediária deve ser diminuída na fração de 1/2, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

II.2 Do crime do art. 34 da Lei de Drogas

No caso concreto, não há prova suficiente da materialidade.

Como se sabe, a condenação criminal exige um grau muito elevado de probabilidade quanto às alegações de fato, a ponto de haver o dever de absolver quando não há provas ou quando existe uma dúvida razoável em favor do acusado:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver

fundada dúvida sobre sua existência;
de 2008)

(Redação dada pela Lei nº 11.690,

VII - não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II - ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas;
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

III - aplicará medida de segurança, se cabível. (grifos acrescidos)

No caso concreto, as provas não sustentam a acusação suficientemente.

Segundo a denúncia, o Réu foi surpreendido com 73 pinos vazios, 02 balanças de precisão e 01 pote de pó royal.

Sucedem que a posse de tais utensílios não encontra aptidão para tipificar o delito em epígrafe, previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006, abaixo transcrito:

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Isso porque, ainda que as circunstâncias da apreensão demonstrem que os objetos apreendidos se relacionam à prática do tráfico de drogas, não é possível afirmar que esses se destinavam especificamente à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, conforme especial fim de agir exigido pelo tipo penal em comento.

Afinal, ainda que objetos como a balança de precisão, pinos eppendorf e dichavadores sejam utilizados comumente para embalagem, separação e pesagem de drogas, estas condutas não se inserem ou confundem com os conceitos de fabricar, preparar, produzir ou transformar drogas, os quais devem ter seu significado extraído a partir de uma interpretação estrita, como corolário do princípio da legalidade.

Nessa senda, como leciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, fabricação consiste na "produção em larga escala"; preparação significa a "obtenção de algo por meio da composição de elementos"; produção é "manufaturar ou fazer surgir em menor escala" e, por derradeiro, transformação traduz-se na "alteração da composição original" (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1216.).

Assim, pelo que consta nos autos, os utensílios apreendidos supostamente com o réu se destinavam não à preparação, fabricação, produção ou transformação das drogas - conforme conceitos acima explanados -, mas à distribuição e embalo dos entorpecentes já previamente preparados/produzidos ou fabricados, para a venda, finalidade esta que não se amolda aos limites do tipo penal.

Este, aliás, o entendimento da doutrina acerca do tema:

"Cumpram-se destacar que nem todo aparelho utilizado no contexto da narcotráfica enseja a incidência do art. 34 da lei 11.343/2006. É precisamente o que ocorre com a apreensão isolada de uma balança de precisão, pois se for 'provado nos autos que a balança se destinava à medida individual de porções destinadas ao consumo, e não à fabricação, produção ou preparo da substância entorpecente, afasta-se aquela imputação - art. 34'.

Nessa linha de raciocínio, é forçoso reconhecer que embora objetos como balança e sacos plásticos possam servir para evidenciar a prática do tráfico de drogas, tais instrumentos não levam automaticamente à condenação do agente pelo art. 34 da Lei 11.343/2006.

De fato, as balanças apenas pesam a droga e os sacos plásticos se prestam unicamente a acondicioná-la. Logo, embora evidentemente os petrechos sirvam para a prática do tráfico de drogas, tais objetos não podem ser equiparados a instrumentos aptos a fabricar (produzir em larga escala), preparar (obter produto por meio da composição de elementos), produzir (manufaturar ou fazer surgir em menor escala) ou

transformar (alterar a composição primitiva) drogas" MASSOM, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. (fls. 92/93) - destaquei

No mesmo sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.511.301 - AC (2015/0023950-6) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE RECORRIDO : EDNILSON PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO : ULISSES D'ÁVILA MODESTO E OUTRO (S) - AC000133 DECISÃO "[...] A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não merece reparo. Conforme decidido, a posse de balança de precisão e sacolas plásticas, por si só, não permitem a fabricação, o preparo, a produção ou transformação das drogas, mas sim a pesagem, acondicionamento e a embalagem dos entorpecentes, logo a absolvição deve ser mantida, como posto pelas instâncias ordinárias, em razão da atipicidade da conduta." [...] (STJ - REsp: 1511301 AC 2015/0023950-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/11/2018) - destaquei

"PENAL. PETRECHOS PARA O TRÁFICO (ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM . PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006). INOCORRÊNCIA. 1. A apreensão isolada de uma balança não implica, per se, necessária subsunção da conduta ao tipo descrito no art. 34 da Lei n. 11.343/2006. 2. Provado nos autos que a balança se destinava à medida individual de porções destinadas ao consumo, e não à fabricação, produção ou preparo da substância entorpecente, afasta-se aquela imputação - art. 34 -, por atipicidade. 3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 pune, com maior rigor, a distribuição de entorpecentes nas proximidades de estabelecimentos ou locais nela previstos. Se ficou comprovado que a ré não foi presa distribuindo entorpecente nas dependências ou imediações dos locais referidos na norma, porquanto a droga foi apreendida no interior da residência da ré, inaplicável a causa de aumento. 4. Ordem concedida para excluir a condenação decorrente do art. 34 da Lei n. 11.343/2006, afastar a causa de aumento nela prevista (art. 40, III), e estabelecer a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença condenatória." (HC 153.322/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 03/11/2011) - destaquei

MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha, cocaína e crack). AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga em poder dos réus e do menor - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - quantidade e variedade, incomum com a figura do usuário; apreensão de dinheiro, balança de precisão e material para embalagem - de rigor a condenação dos réus - provimento ao recurso ministerial. CAUSA DE AUMENTO - prática do delito que envolveu adolescente - causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ausência de prova de estabilidade e permanência - de rigor a absolvição - improvimento ao apelo ministerial. PETRECHOS DE FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES - insumo químico utilizado como precursor para fabricação e síntese de entorpecentes - apreensão de facão, tesoura, balança de precisão e embalagens vazias - petrechos e insumo que não integra a descrição do tipo - atipicidade - de rigor a absolvição - improvimento para este fim. [...] (TJ-SP - APR: 15017475920178260536 SP 1501747-59.2017.8.26.0536, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 06/10/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE OBJETOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DROGAS. I - Petrechos para a produção de drogas. Atipicidade da conduta. Absolvição. Necessidade. A apreensão de duas balanças de precisão não se afigura suficiente a caracterizar o delito previsto no art. 34 da Lei 11.343/06, pois, embora se tratem de material rotineiramente utilizado no tráfico de entorpecentes, ele não se destina à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Além disso, o referido tipo penal possui natureza subsidiária ao crime tipificado no art. 33 da mesma legislação. II - Penas e regime prisional mantidos em relação ao tráfico de drogas. Redutor não aplicado, pois há provas de que o acusado dedica-se ao tráfico, segundo as mensagens de seu celular e apreensão de enorme quantidade e variedades de drogas em seu poder. Pena de multa inalterada. Regime prisional mantido. Restituição de veículo apreendido. Ausência de comprovação da origem lícita Confisco mantido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00974142320158260050 SP 0097414-23.2015.8.26.0050, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 20/09/2018, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/09/2018) - destaquei

MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga na casa e no carro do réu Danilo e, ainda, no sítio onde trabalhava como caseiro o réu Ronivaldo - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade e variedade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, algumas já embaladas para a venda a varejo e outras prontas para serem divididas em porções menores; apreensão de balança de precisão, material para embalagem de drogas e grande quantidade de dinheiro; denúncia. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - prova oral confirmando que os acusados se associaram de forma estável e permanente para o tráfico de drogas - improvimento aos apelos dos réus. PETRECHOS DE FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES - balança, prensas e embalagens - não integra a descrição do tipo - atipicidade - de rigor a absolvição - provimento para este fim. POSSE DE ARMA - materialidade comprovada pela apreensão e perícia da arma, apta a disparos e sem documentação regular - a supressão da numeração da arma comprovada pelo laudo pericial. AUTORIA - depoimento de policiais que indica a apreensão da arma no sítio onde o acusado Ronivaldo era o caseiro - incontestes a responsabilidade do réu Danilo também pela arma - responsabilidade do réu Danilo pela distribuição de drogas, claro que mantinha a arma para qualquer eventualidade envolvendo os entorpecentes - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - improvimento ao apelo do réu Danilo. [...]. (TJ-SP - APR: 00002376120188260080 SP 0000237-61.2018.8.26.0080, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 23/05/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2019) - destaquei

PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO - caso em que se adentrou a residência em situação de flagrante delito - uma das hipóteses garantida pela Constituição Federal - ocultação de drogas no interior da casa - delito permanente - constante o estado de flagrante - busca e apreensão amparada em fundadas suspeitas, já que os policiais puderam confirmar as denúncias anônimas ao constatarem o réu que reunia as características físicas declinadas saindo de local também indicado na denúncia como sendo o imóvel onde eram guardadas as armas e drogas - inexistência de ilegalidade - licitude da diligência realizada - licitude das provas colhidas em face do flagrante - preliminar afastada. PETRECHOS DE FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES - balança e embalagens vazias - não integra a descrição do tipo - atipicidade - de rigor a absolvição - provimento para este fim. TRÁFICO - MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. [...]. (TJ-SP 00355998820168260050 SP 0035599-88.2016.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 10/05/2018, 12ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de

Publicação: 18/05/2018)

Diante da inutilidade dos objetos apreendidos para as condutas previstas no tipo penal do art. 34, a prova oral não é capaz de preencher as exigências de materialidade.

Desta forma, o Réu deve ser absolvido com base no art. 386, II, do CPP.

II.3 Do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do delito restou devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 15/16), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), das fotos de fls. 42 e 46, do laudo pericial (fls. 207/210), bem como provas orais produzidas nos autos.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha DAVISON DANIEL BATISTA afirmou que: estava em patrulhamento pelo Terminal Rodoviário; quando entraram na rodoviária, perto da plataforma de passageiros, o Réu jogou uma sacola no chão e saiu correndo, ao ver a viatura; pegaram a mochila; o parceiro conseguiu correr atrás dele e abordá-lo; na posse do Réu, só havia um celular; na mochila, havia um revólver calibre .38, drogas e dinheiro; em entrevista com o Réu, ele falou que iria para Carapicuíba fugir do comprimento de um mandado de prisão e que a arma era para proteção dele, em razão de desafetos que tinha na região; o Réu falou que tinha comprado a arma em Lorena; na delegacia, tomaram conhecimento de um mandado de busca domiciliar; foram até a casa dele para apoiar os policiais civis; no local, encontraram mais drogas e dinheiro, bem como balança de precisão, que ele reconheceu como dele; na mochila, encontraram maconha e cocaína.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha MAURÍCIO DA CONCEIÇÃO SILVA afirmou que: estavam em patrulha próximos ao Terminal Rodoviário; viram o Réu; quando o Réu viu a viatura, jogou a mochila no chão e fugiu; recuperaram a mochila e foram atrás do Réu; o Réu foi abordado e com ele nada de ilícito foi encontrado; na mochila, havia um revólver calibre .38, maconha e cocaína; encaminharam para a delegacia de Cachoeira Paulista; na delegacia, souberam de um mandado de prisão contra o Réu e um mandado de busca domiciliar; junto com a equipe da PCSP, foram até a residência e encontraram drogas e outros objetos, que foram apreendidos.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha LUÍS CÉSAR FRANKLIN afirmou que: a PM fazia patrulhamento perto da rodoviária e visualizou o Réu; sabiam que o Réu estava com um mandado de prisão preventiva; o Réu viu os policiais e fugiu, deixando uma mochila para trás; os PM detiveram o Réu e, na mochila, encontraram um revólver calibre .38, maconha e cocaína; os PM conduziram o Réu até a delegacia; a autoridade policial determinou que dessem cumprimento ao mandado de busca na casa do Réu; foram até o local com a PM; lá, encontraram mais 16 pinos de cocaína, balanças de precisão e pinos vazios; além disso, colheram outros elementos ligados a um furto de que ele é investigado; o Réu estava com uma passagem para Carapicuíba, com intenção de ir para aquela cidade;

Em sua oitiva em juízo, a informante HARIADNY DE FREITAS afirmou que: o Réu mora na mesma casa dela (é padasto); pelo que sabe, o Réu sempre trabalhou; o Réu trabalhou um tempo no caminhão de lixo; é um bom padasto; quando o Réu foi preso, ele morava com a mãe; o Réu nunca teve envolvimento com tráfico de drogas;

Em sua oitiva em juízo, a informante VERA LUCIA FABIANO afirmou que: o Réu é um bom filho; no dia em que os policiais foram, tinha viajado para SP; ligaram informando que o policial tinha entrado na casa delas; o Réu não mora com ela; o Réu mora do lado de fora; os policiais arrebitaram o portão e entraram; só chamaram depois o

irmão do Réu; os irmãos não viram o que levaram; levaram a televisão e outros móveis; arrebataram a porta de casa; não sabe da localização de drogas; sabia que o Réu era usuário de drogas; o Réu morava com a esposa, na Margem Esquerda, n. 29 de março, n. 25; a informante mora na Rua Redenção da Serra, n. 335; Em seu interrogatório, o Réu MARCO AURÉLIO FABIANO afirmou que: com ele, encontraram maconha, cocaína e o revólver calibre .38; estava indo para Carapicuíba; só tinha a droga que estava com ele; a rua Redenção da Serra é o endereço da mãe; a casa da mãe tava vazia; quando entraram na casa, não tinha ninguém; o irmão morava no fundo; estava no local há 2 ou 3 dias; estava fugindo do mandado de prisão, para se apresentar; nega as drogas na rua Redenção da Serra; A autoria restou igualmente comprovada pela prova oral, a qual foi colhida no seguinte sentido: o Réu, de fato, foi encontrado com um revólver calibre .38, com numeração suprimida, em sua mochila, após abordagem nas redondezas do terminal rodoviário.

Salienta-se que os depoimentos policiais foram harmônicos entre si, tanto em sede policial quanto em juízo, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia. Ademais, as alegações de fato contidas na denúncia são corroboradas a partir do laudo pericial (fls. 207/210) o qual constatou um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração de identificação suprimida, bem como acessórios e munições para os respectivos armamentos.

Em relação à arma, o laudo pericial concluiu estar apta à realização de disparos, sem constatação de disparos recentes (fls. 209).

Ato contínuo, consigno que os crimes em questão dispensam a ocorrência de perigo efetivo, perfazendo-se com o porte e a posse, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regular, de arma de fogo e munições, pouco importando o destino que se daria a elas, ou seja, caça, defesa pessoal, prática de crimes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ O crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta. Precedentes.” (AgRg no RHC 86.862/SP, j. 20/02/2018)

“A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o